

1500113-25.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e aplicação do regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando-se, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500113-25.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500113-25.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021563/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 22618138 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 314/22/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2021563 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ ALISSON FIDELES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

ANDRÉ ALISSON FIDELES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e está sendo processado porque, no dia 24 de janeiro de 2022, no horário e no endereço mencionados na denúncia, teria trazido consigo, para fins de tráfico ilícito, drogas, consistentes em 7 papелotes de cocaína (pesando,

aproximadamente, 2 gramas - peso bruto) e 53 pedras de crack (pesando, aproximadamente, 31 gramas - peso bruto), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado por edital a fls. 143 e pessoalmente a fls. 227.

A defesa preliminar foi apresentada às fls. 199/200.

A denúncia foi recebida às fls. 204/206.

Citado (fls. 233), em audiência de instrução e julgamento (fls. 234), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais (gravação constante dos autos), requereu a integral procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação do acusado, com o afastamento, ainda, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 237/243, requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e aplicação do regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando-se, ainda, a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), pelas razões abaixo mencionadas.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 10, pelas fotografias de fls. 22/23, pelo comprovante de depósito de fls. 74, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 144/146, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, restou inequívoca.

O réu André Alisson Fideles da Silva, na fase policial (fls. 05), negou a prática do crime, aduzindo que: estava no bairro Imperial, na casa da sua tia, quando foi até a "Seletinha"; ao passar por um beco, viu motocicletas da ROCAM; nesse momento, sequer sabia o que estava acontecendo; os agentes policiais passaram e encontraram uma sacola plástica perto da sua pessoa, a cerca de 7 metros de distância; os entorpecentes não são de sua propriedade.

Em juízo, contudo, confessou a prática delitiva, afirmando que: possui 19 anos de idade; possui um filho de dois meses de idade; antes de ser preso, trabalhava como servente de pedreiro; não possui condenações criminais; possui duas condenações pela prática de atos infracionais (ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, cometido na cidade de Mairiporã; e ato infracional equiparado ao crime de receptação, cometido na cidade de Atibaia); pela prática do ato infracional equiparado ao delito de receptação, ficou internado na Fundação Casa por 10 meses;

pela prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico, ficou internado na Fundação Casa por 6 meses; a sacola plástica contendo entorpecentes realmente lhe pertencia; era a primeira semana que vendia drogas; devido ao fato de estar passando por necessidades financeiras e por não suportar o trabalho como servente de pedreiro, decidiu comercializar entorpecentes; está arrependido da prática do delito e por ter mentido na fase policial.

Tal confissão merece ser considerada pelo Juízo.

Isto porque o policial militar Filipi Barbosa Bucciarelli, em juízo, relatou que: na data dos fatos, estavam em patrulhamento com motocicletas, pelo bairro Caetetuba, em local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o réu com uma sacola plástica nas mãos; o acusado estava num ponto onde há o cruzamento de uma rua com uma viela, local este conhecido principalmente pela comercialização de crack; ao avistar a aproximação da equipe policial, o acusado jogou a sacola plástica ao chão e saiu caminhando "a passos acelerados"; saiu no encalço do réu e conseguiu abordá-lo a cerca de sete metros de distância da mencionada sacola plástica; realizada busca pessoal no acusado, nada de ilícito foi encontrado; ao verificarem a sacola plástica que o acusado havia dispensado ao chão, localizaram no interior dela 53 pedras de crack e 7 porções de cocaína; encontraram, ainda, a quantia de 16 reais em dinheiro em poder do acusado; ao ser questionado sobre os entorpecentes, o acusado preferiu se manter em silêncio; não havia pessoas próximas ao réu no momento da abordagem; visualizou nitidamente o réu em poder da sacola e a dispensando ao chão, pois ainda havia luz solar; as porções de entorpecente estavam todas individualizadas, prontas para a venda; não conhecia o acusado anteriormente.

Por fim, nesse mesmo sentido, o policial militar Gabriel Bueno, em juízo, narrou que: por ocasião dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Caetetuba, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado com uma sacola plástica nas mãos; ao perceber a aproximação da equipe policial, o réu dispensou a sacola plástica ao chão e se afastou do local rapidamente; saíram no encalço do acusado e lograram êxito em abordá-lo a cerca de cinco metros de distância do local em que a sacola foi dispensada; recuperaram a mencionada sacola plástica e, no interior dela, encontraram porções de crack e de cocaína; realizada busca pessoal, encontraram uma quantia em dinheiro no bolso do acusado; o acusado não forneceu qualquer versão acerca dos fatos; o acusado estava sozinho no local da abordagem; não conhecia o réu anteriormente; as porções de entorpecente estavam individualizadas e prontas para a comercialização; visualizaram de forma nítida o réu em poder da sacola plástica, assim como o momento em que ele a dispensou ao chão.

Nesse contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, pelos seguintes motivos: i - expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos pelos policiais militares (53 porções de crack e 7 porções de cocaína); ii - forma de acondicionamento das drogas (em porções individualizadas), a indicar que se destinavam à comercialização; iii - confissão do acusado em juízo (confessou a propriedade de todos os entorpecentes e confessou que eles se destinavam à comercialização); iv - depoimento harmônico dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do acusado; v - apreensão de quantia em dinheiro em poder do réu (R\$ 16,00), sem comprovação de origem lícita; vi - local da abordagem conhecido nos meios policiais como ponto de intenso tráfico de drogas; e vii - acusado com duas condenações definitivas na Vara da Infância e Juventude, sendo uma delas, inclusive, pela prática de ato infracional análogo ao delito em julgamento (tráfico de drogas), cf. certidão de distribuição de fls. 27/28, consulta de processos de fls. 75/76, documentos de fls. 81/100 (cópias extraídas de outros processos) e certidão de objeto e pé de fls. 125.

Com efeito, o acusado, em juízo, confessou que todos os entorpecentes apreendidos

(56 porções de crack e 7 porções de cocaína) lhes pertenciam, bem como confessou que estava comercializando entorpecentes há cerca de uma semana.

Além disso, afirmou estar arrependido de ter mentido em solo policial, ocasião em que aduziu que os entorpecentes não lhe pertenciam.

Tal confissão, a toda evidência, merece ser considerada pelo Juízo como meio de prova, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, haja vista se encontrar em consonância com as demais provas carreadas aos autos, mormente com o depoimento dos policiais militares.

Nesse viés, destaco que policiais militares Filipi e Gabriel, tanto em solo policial quanto em juízo, de forma coesa e verossímil, relataram que avistaram o acusado, em local conhecido nos meios policiais como ponto de intenso tráfico de drogas, com uma sacola plástica nas mãos.

Narraram, ainda, que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o acusado dispensou a mencionada sacola plástica ao chão e saiu caminhando de forma rápida.

Aduziram, também, que lograram abordar o acusado a poucos metros de distância do local em que a sacola foi dispensada (cerca de 5 a 7 metros), e que, no interior da referida sacola, encontraram porções individuais de crack e de cocaína.

Outrossim, referidos agentes policiais foram firmes ao narrarem que o réu estava sozinho no local da abordagem e que o visualizaram de forma nítida em poder da sacola (posto que ainda havia luz solar).

Sendo assim, a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

No mais, quanto ao montante em dinheiro apreendido em poder do réu (16 reais), dúvidas não restam de que se trata de montante oriundo da mercancia ilícita.

Isto porque, além de confessar que estava traficando há, aproximadamente, uma semana, o acusado não informou a origem do montante apreendido, só restando concluir, portanto, que se trata de quantia proveniente do tráfico de drogas.

Por tal motivo, a decretação de perda do montante apreendido é medida que se impõe - o que se dará mais adiante, na parte dispositiva da presente sentença.

Devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, no mais, revela-se incabível a aplicação do redutor (causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), tendo em vista o fato de o acusado possuir condenações definitivas, com trânsito em julgado, pela Vara da Infância e Juventude, sendo uma delas, inclusive, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (cf. informado pelo próprio acusado no início do interrogatório judicial e corroborado pelos documentos de fls. 81/100 e pela certidão de fls. 125), circunstância esta que, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, indica efetiva dedicação a atividades criminosas.

No sentido do exposto:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE

MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma. (...)" (STJ - HC: 364837 SP 2016/0199722-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

Por fim, acerca da alegação feita pelo acusado (autodefesa), em juízo, no sentido de que cometeu o crime devido ao fato de estar passando por dificuldades financeiras, destaco que tal alegação revela-se insuficiente para eventual reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Acerca do assunto, ensina Cleber Masson ("Código Penal Comentado", Editora Método, 3ª edição, 2015, p. 195/196), ao comentar a distinção entre a referida excludente (estado de necessidade) e as dificuldades econômicas, que: "Não se confundem. No estado de necessidade, o agente é compelido a praticar o fato típico, para afastar a situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiro, cujo sacrifício é inexigível. Na dificuldade econômica supõe-se que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária, ou, ainda que disso se trate, que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita. Em qualquer das hipóteses não se justifica a lesão ao interesse de outrem. Destarte, a dificuldade econômica, inclusive com a miserabilidade do agente, não constitui estado de necessidade. Em casos excepcionais, admite-se a prática de um fato típico como medida inevitável, ou seja, para satisfação de necessidade estritamente vital que a pessoa, nada obstante seu empenho, não conseguiu superar de forma lícita, a exemplo do furto famélico, em que o sujeito subtrai alimentos básicos para saciar a sua fome ou de pessoa a ele ligada por laços de parentesco ou de amizade. Portanto, se o agente podia laborar honestamente, ou então quando se apodera de bens supérfluos ou em quantidade exagerada, afasta-se a justificativa".

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça também decidiu que:

"Estado de necessidade - dificuldades financeiras - não caracterização: a afetação da qualidade de vida, mesmo implicando em dificuldades financeiras, por si só, não preenche os requisitos do status necessitatis (art. 24 do CP)" (REsp 499.442/PE, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 24.06.2003)

Ademais, imperioso realçar que o réu não comprovou a existência de dificuldade econômica e de perigo atual que justificassem o sacrifício de bem alheio, ônus da prova que, a toda evidência, lhe competia (art. 156, do Código de Processo Penal).

Nesse aspecto, destaco que a Defesa sequer arrolou testemunhas para confirmação, em juízo, das alegações do acusado.

Assim sendo, só resta concluir que a conduta do acusado não se amoldou às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, razão pela qual se revela impossível o seu reconhecimento no caso concreto.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, afastando-se, ainda, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Verificadas, assim, materialidade e autoria delitivas, passo, pois, à fixação da pena.

Na dosagem da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos, verifico que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em vista a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (53 porções de crack e 7 porções de cocaína). Outrossim, considero, também, a natureza dos entorpecentes (ambos de elevada nocividade, mormente o crack). Por tais motivos, aumento a pena mínima em 1/6, perfazendo a pena-base 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência das atenuantes genéricas da menoridade relativa (o acusado possuía, à época dos fatos, 18 anos de idade) e confissão espontânea, de forma que retorno sua pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), uma vez que tais atenuantes não possuem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo, nos termos da súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, na terceira fase, consigno que o acusado não faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelos motivos supramencionados.

Ausentes demais circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena acima fixada, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquelas genericamente fornecidas por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficientes para tal finalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado. O réu, além disso, é primário, relativamente menor e confessou integralmente a prática delitiva.

Destaco, ademais, que não se mostra cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada ao réu (superior a 04 anos) – art. 44, inc. I, do Código Penal. Ainda, de se observar que tal medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso, tendo em vista a sua gravidade em concreto – requisitos subjetivos (art. 44, inc. III, do Código Penal).

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos que culminaram com a decretação de sua prisão preventiva. A detração, para fins de eventual progressão (o acusado se encontra preso, preventivamente, há pouco mais de um mês), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra ANDRÉ ALISSON FIDELES DA SILVA e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial semiaberto, sem conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e sem o direito de recorrer em liberdade.

Oficie-se ao estabelecimento prisional no qual o acusado se encontra recolhido para que promova a adequação ao regime inicial ora fixado (semiaberto).

Com o trânsito em julgado:

I - lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos); e

II - oficie-se ao FUNAD com relação ao numerário depositado a fls. 74, cuja perda ora decreto, haja vista ter restado comprovada a origem ilícita do montante.

O réu está isento do pagamento de custas processuais, uma vez se encontra assistido por Defensora nomeada em razão do convênio firmado entre a OAB/SP e a DPE/SP (fls. 201/203), presumindo-se, dessa forma, o seu estado de miserabilidade e a impossibilidade financeira de arcar com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor da Defensora nomeada.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA